

الدرس الثامن : انعقاد عقد القرض الاستهلاكي

أولاً: التراضي

تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي 2015 أن عرض القرض المسبق يسبق عقد القرض كما تنص أيضا المادة 20 من قانون حماية المستهلك على شفافية العرض المسبق وهذا يقتضي أن المشرع الجزائري اعتبر صراحة العرض المسبق مرحلة تمهيدية وسابقة على التعاقد بينما تدرجه بعض التشريعات في الانعقاد.

فانعقاد عقد القرض يتطلب تراضي من إيجاب وقبول والقواعد العامة تتعرض للتراضي من المادة 59 وما يليها من القانون المدني ويثور التساؤل هل يمكن تطبيقها في إطار عقد القرض. تنص المادة 2/2 من المرسوم التنفيذي 2015 المذكور أعلاه على ما يلي: (عقد القرض: عقد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول تجاه المستهلك بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط مماثل).

ويتضمن هذا النص أن القبول يكون من البائع أو المقرض مما يتضمن حتما أن الإيجاب يصدر من المشتري أو المقرض.

وهذا مخالف لما تضمنته أغلب التشريعات حيث تنص هذه الأخيرة أن الإيجاب يصدر من المقرض ويلزم ببقائه على إيجابه مدة معينة والقبول يصدر من المقرض وتأتي بعد ذلك حماية هذا الرضا بقواعد متعددة.

ولكن في الحقيقة من الناحية العملية صحيح أن المقرض هو الذي يتقدم بطلب القرض وهذا الذي جعل التردد في تحديد من يصدر منه الإيجاب ومن يصدر منه القبول خاصة أن غالبية التشريعات تذهب إلى أن إيجاب المقرض يتضمن غالبا تحفظ المقرض على قبول المقرض لاحقا لأن المؤسسات المصرفية تقوم بدراسة الوضعية المالية للمقرض كما سبق بيان ذلك بصدد قواعد الحذر بينما تقتضي القواعد المنظمة للإيجاب في القواعد العامة أن يكون الإيجاب باتا ومحددا وإمكانية رفض المقرض للمقرض يخالف ذلك تماما.

وقد ذهبت التشريعات إلى منح المقرض صفة الموجب بنصوص أمرة.

بينما المشرع الجزائري في النص السابق الذكر يجعل القبول يصدر من المقرض وهذا الموضوع له أهمية بالغة في تحقيق حماية للمستهلك من عدمه أي المقرض في هذا المجال سنتعرض لها لاحقا.

ويلاحظ في هذا المجال أنه تطبق على عقد القرض الاستهلاكي القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني في مجال عوارض الأهلية وعيوب الإرادة إذ لا يوجد نص خاص يخالف ذلك.

و لم يكتف المشرع بالتراضي بل أن عقد القرض الاستهلاكي يشترط فيه الكتابة وفقا لنص المادة 20 من قانون حماية المستهلك المذكورة سابقا إذ تتضمن: (... ويحرر عقد بذلك...)

وأصبحت جميع عقود الائتمان المصرفية تتطلب الشكلية ولكن يتطلب في ذلك الكتابة فقط والكتابة تحقق حماية المقرض والمقرض.

فالمقرض ليدرك خطورة العقد وللمقرض حيث تيسر له عملية الاثبات في حالة النزاع لاحقا.

وتقتضي القواعد العامة في الانعقاد أنه إذا تراضى الطرفان وتم مراعاة الشكلية المطلوبة في الانعقاد وانعقد العقد فلا يمكن لأحد الأطراف التراجع عنه أو تعديله بالإرادة المنفردة وهذا هو مضمون القوة الإلزامية للعقد الواردة في المادة 107 مدني.

لكن قواعد قانون القرض والنقد ومرسوم 2015 يتعرضان لخلاف ذلك فيمنحان للمقرض حق التراجع ، و كذلك قانون حماية المستهلك وفقا لتعديل ماي 2018 .

كما تنص المادة 2/11 من مرسوم 2015 على ما يلي: غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية (8) أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء العقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والنص يخص المشتري المقرض علما أن مهلة التراجع على العقد أصبحت في جميع التشريعات حق من حقوق المستهلك أي كان العقد الذي يبرمه إلا أن المشرع الجزائري نص في المادة 3/12 من مرسوم

2015 على ما يلي: ويبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام المبينة أعلاه .

يستنتج من هذا أن حق التراجع منح للمشتري بصدد الدفع المقسط أو المؤجل لأن إذا دفع المبلغ المستحق كله لا يمكنه بعد ذلك ممارسة حق التراجع .

ومن أهم الحقوق التي منحت للمستهلك هو الحق في التراجع وإن كانت المسألة قد تردد الفقه في تكييفها بل أن البعض يفضل مهلة التفكير نتيجة صعوبة تقبل فقهاء القانون المدني فكرة ترك مهلة للشخص يمكنه التراجع فيها عن العقد الذي تم إبرامه.

إلى جانب أنه قيل من الناحية العملية نادرا ما يستعمل هذا الحق إذ لن تكون للمستهلك جراءة للتراجع بعد التعاقد، لهذا يفضل مهلة التفكير وأن المشرع نص في العديد من المواد على مهلة التفكير مثلا المادة 4 من قانون الممارسات التجارية لسنة 2006 والمادة 20 من قانون حماية المستهلك لسنة 2009 غير أن الواقع العملي اثبت أن هذه المهلة غير مفيدة أحيانا بل يجب أن تكون أيضا للمستهلك إمكانية التراجع ويلاحظ أن المشرع نص على ذلك في المادة 1/119 من قانون سنة 2010. والنص خاص بالزبون وليس فقط المستهلك فقد يكون الزبون محترفا.

وقد ثار تحديد الطبيعة القانونية لحق التراجع جدلا ومحاولة إدراجه ضمن الأنماط المعروفة سواء الوعد أو الشرط أو البيع بالعربون أو الفسخ بالإرادة المنفردة وسأحاول باختصار تأصيل المسألة.

فالقول أن تراجع المشتري بمثابة وعد بالبيع بحيث يظل للمستهلك حق القبول أو الرفض ولكن القبول في الوعد يبيده الموعد له متى شاء ما دام المدة المحددة لم تنقض، ولا يمكن أن يستخلص قبوله ضمنا وفقا للمواد 71 و 72 من القانون المدني بينما المستهلك يبدي التراجع قبل فوات المدة الممنوحة له للتراجع كما أن فوات المدة دون تراجع يستخلص منه قبوله.

ويكيف البعض التراجع بأنه بمثابة شرط فاسخ ولكن الشرط كوصف للالتزام يجب أن يكون أمر عارض غير متوقف على الإرادة بينما القبول في عقد البيع أمر جوهري ومتعلق بالإرادة المحضة. (وفقا لنص المادتين 203 و 205 من القانون المدني).

لهذا قيل أيضا أن التراجع بمثابة بند فاسخ ولكن البند الفاسخ يراقب في استعماله عدم التعسف باعتباره من الممارسات أو الصلاحيات التي يجب أن يكون ممارستها غير متعسف.

بينما التراجع يمارسه المستهلك كيفما شاء دون رقابة إلى درجة أن البعض يرى أن هذا الحق يعد تراجعاً على مبدأ حسن النية في التعاقد بل يتعارض مع نظرية التعسف في استعمال الحق عموماً وينادون بضرورة وضع ضوابط له لكن المشرع لم يضع أي ضابط لممارسة هذا الحق. وقد نصت المادة 19 فقرة 2 و 3 من القانون 19-08 المعدل والمتمم لقانون حماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي ((.....))

العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتج ما دون وجه سبب.

للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف إضافية.

((.....))

وقد حاول البعض أيضاً تقريبه من التعاقد بالعربون الوارد في المادة 72 مكرر مدني وقيل أن العقد ينعقد ولكن المستهلك يحتفظ بخيار العدول ولكن لخيار العدول مقابل يدفعه من عدل عن العقد بينما من المميزات الأساسية للحق في التراجع أنه مجاني يمارسه المستهلك دون مقابل

ولعله لا يمكننا تفسير حق التراجع بالاستناد إلى القواعد العامة وأن جميع محاولات بأت بالفشل لأنه آلية جديدة غريبة على هو متعارف عليه في القانون المدني بخصوص قواعد انعقاد العقد

يلاحظ أن المشرع الجزائري على خلاف معظم التشريعات لم يبرز ولم ينظم كيفية ممارسة هذا الحق ولم يضع له جزاء خاص

فما أهمية إدراج هذا الحق دون جزاء ؟